

0016165-22.2002.8.26.0045

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

0016165-22.2002.8.26.0045 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0016165-22.2002.8.26.0045

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcus Vinicius da Silva Barbosa

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 12, da Lei nº 6.368/76, pois, no dia 03 de maio de 2002, aproximadamente às 19h30min, na Rua Porto Alegre, s/nº, Bairro Jardim Real, nesta Comarca, o acusado vendeu e trazia consigo, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, policiais civis estavam em diligências para apuração de denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes, no local dos fatos surpreenderam Cláudia sentada ao volante de um veículo parado, e Marcus Vinicius junto à porta do Motorista. Com a aproximação dos policiais Marcus Vinicius dispensou para dentro do carro um invólucro plástico que trazia consigo, o qual Cláudia lançou para fora do veículo, contendo nove papелotes de cocaína e uma "bagana" de cannabis sativa L, substância popularmente conhecida como maconha (auto de apreensão de fls. 15 e auto de constatação de fls. 17); a quantidade e a forma de condicionamento dos entorpecentes, as circunstâncias da ação criminosa e as circunstâncias da prisão permitem a caracterização segura da finalidade de tráfico. Auto de prisão em flagrante (fls. 05/10). Boletim de ocorrência (fls. 12/14). Auto de exibição e apreensão (fls. 15). Laudo constatação (fls. 17). Folha de

anteriores (fls. 330/332).

Foi recebida a denúncia em 14 de Agosto de 2002 (fls. 51-v).

O réu foi citado por edital e apresentou defesa preliminar (fls. 297).

Em decisão do dia 07 de julho de 2010 (fls. 305), foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional.

Diante da citação pessoal do réu, foi revogada a suspensão em decisão datada de 11 de maio de 2021 (fls. 391/393)

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha (fls. 450/451).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais em audiência, postulando pela improcedência da ação, com a consequente absolvição do réu. Diante da oitiva de apenas uma testemunha, e não havendo amparo em outros elementos de prova trazidos aos autos, especialmente sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo com o que cotejar o depoimento da testemunha, em que pese, bastante detalhado o relato

A defesa, por seu turno, em alegações finais orais, aduziu que considerando o que dos autos consta, bem como, as alegações do Ministério Público, reiterou o pedido pela improcedência da ação, com a consequente absolvição do acusado.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A materialidade está demonstrada conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, não restou satisfatoriamente comprovada.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha Milton dos Santos Moreira Junior, policial civil aposentado, disse que o caso em tela foi um dos primeiros investigados no bairro Jardim Real, na pista de skate, da rua Amazonas, informa que receberam uma denúncia de que no bar/mercearia da Olga, estava sendo utilizado por um rapaz, foi dado a sua descrição, para a prática de tráfico de entorpecentes no período noturno. Diante da denúncia, foram até o local, com a viatura totalmente desligada, quando na Rua Porto Alegre, se depararam com um veículo, salvo engano um Tempa, preto, onde na sua condução estava a Cláudia, e o acusado Marcus Vinicius estava debruçado na janela, em seguida, desembarcaram da viatura, foram em direção aos dois, quando estavam e aproximando foram vistos o acusado soltou os entorpecentes dentro do veículo, abordaram os dois, pediram para que a Cláudia descesse do carro, verificaram que o entorpecente ficou entre a porta e o banco do motorista, cerca de 10 papérolas de cocaína e 02 trouxinhas de maconha, e com o acusado Marcus Vinicius, o policial Almir encontrou dinheiro, cerca R\$ 30,00, conduzindo logo em seguida os dois para a delegacia.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Pela prova colhida nos autos, não há certeza de que o réu possuía drogas para fins de tráfico.

Os exames toxicológicos confirmaram a natureza entorpecente das drogas localizadas, sendo apurado que havia 5,98g de massa líquida de cocaína, 4,6g de massa líquida de maconha.

Em audiência de instrução, ausente o réu, não houve interrogatório, tendo sido decretada a sua revelia.

O policial civil narrou como abordaram o acusado na data dos fatos, indicando que estavam em patrulhamento, investigando denúncia recebida de que o local estava sendo utilizado para a prática do tráfico, e avistaram o réu debruçado na janela do veículo, onde estava a corré Cláudia, e após avistar os policiais o acusado soltou os entorpecentes dentro do veículo, e posteriormente foi abordado, sendo encontrado com o réu em revista corporal, apenas a quantia de R\$ 30,00, os entorpecentes teriam sido encontrados dentro do veículo, entre o banco do motorista e a porta.

Após, foram conduzidos à delegacia.

Com efeito, no caso sub judice, efetivamente de relevante existe apenas o alegado encontro de entorpecentes e o depoimento da testemunha policial no sentido de que

o réu era quem portava a droga.

De todo modo, pela prova oral colhida nos autos, não há certeza de que o réu possuía drogas para fins de tráfico.

Observo, de outro giro, que no depoimento do policial este não informou ter visto o réu praticando efetivamente tráfico de drogas. Ainda, não há notícia de realização de campana que pudesse permitir aos policiais o acompanhamento de ações que indicassem efetiva prática de comércio de drogas pelo acusado.

Vê-se ainda que com o acusado não se localizou, ainda, qualquer outro instrumento para o delito de tráfico de drogas.

A par de tudo isso, como sói ocorrer, não foi trazida qualquer outra testemunha, que estivesse presente no momento do flagrante, mesmo havendo relato de tratar-se de local próximo a pista de skate e bar/mercearia, sendo, neste caso, pouco crível a ausência de outros usuários ou de terceiros no local, no momento do flagrante. É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é composta por depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos. A presente situação não se amolda, todavia, a esta regra, lembrando que no presente autos fora ouvida apenas uma testemunha policial, não havendo, do mesmo modo, outros indicativos seguros da ocorrência do comércio espúrio pelo acusado, sendo ainda forçoso destacar que o fato remonta ainda ao ano de 2002, tendo, desta feita, mais de vinte anos.

Não se trata aqui, de forma alguma, de desqualificar todo e qualquer testemunho prestado por policiais, mas de não olvidar ou ignorar o julgador a possibilidade de ocorrência de falhas perpetradas por estes no exercício de sua função, que podem até incluir imputações precipitadas, pouco apuradas, apressadas.

Em toada semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - NECESSIDADE - PALAVRA ISOLADA DOS POLICIAIS. A versão policial isolada sobre a prática do crime não forma conjunto probatório suficiente para sustentar a convicção sobre a destinação da droga apreendida e, portanto, não autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.16.010381-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018).

Neste sentido também é o ensinamento de Gustavo Badaró:

Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do artigo 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelos simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por ele investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se demonstrem harmônicos entre si (BADARÓ, Gustavo Henrique; Processo Penal. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 477/478). (Grifos nossos)

Em sentido semelhante ao aqui exposto, esclarece, de forma muito didática, Aury Lopes Jr:

Da mesma forma, não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.

Contudo, é recorrente o Ministério Público arrolar como testemunhas apenas os policiais que participaram da operação e da elaboração do inquérito. Busca, com isso, judicializar a palavra dos policiais para driblar a vedação de condenação “exclusivamente” (art. 155 do CPP) com base nos elementos informativos colhidos na investigação. Na continuação, deparamo-nos com sentenças condenatórias em que são utilizados os elementos do inquérito e o depoimento dos policiais em juízo. No fundo, é um golpe de cena, um engodo, pois a condenação se deu, exclusivamente, com base nos atos da fase pré-processual e no depoimento contaminado de seus agentes, natural e profissionalmente comprometidos com o resultado por eles apontado, violando o disposto no art. 155 do CPP. Portanto, se não há impedimento para que os policiais deponham, é elementar que não se pode condenar só com base nos seus atos de investigação e na justificação que fazem em audiência.” (2019, p.462)

Aliás, na linha do que está sendo exposto, se a ideia fosse tomar como absoluta e incontestável toda e qualquer declaração prestada por testemunhas policiais no bojo do processo penal, despicienda seria a instrução probatória e até mesmo a valoração da prova colhida pelo Juiz de Direito. A presunção de inocência, princípio que informa todo o sistema processual penal, e que está prevista como garantia constitucional, também seria invariável e inevitavelmente fulminada.

Outrossim, como este juízo sempre vem asseverando, não é demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a reunião de outros elementos probatórios que não se limitem à mera repetição das declarações dos policiais que efetivaram a prisão do acusado, até porque, como consignado alhures, é natural que estes objetivem legitimar, até inconscientemente, sua própria atuação. Por oportuno, não se pode deixar de registrar, em crimes de natureza diversa do ora apurado, a par dos depoimentos policiais, são em regra produzidos outros elementos de prova, de origens distintas, a exemplo de testemunhos de terceiros, oitiva da vítima, com reconhecimento de pessoa e de objeto, etc, o que sem dúvida contribui para a realização de uma instrução processual mais robusta, com possibilidade de uma construção mais sólida da culpabilidade do agente.

Pontua-se também, mais uma vez, que não foi trazida qualquer testemunha distinta do policial que pudesse corroborar a versão acusatória, o que certamente robusteceria a prova acusatória. Neste sentido são as palavras do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:

Parece-nos cauteloso que o magistrado, visualizando, em processos de apuração de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, um rol de testemunhas de acusação formado somente por policiais, indague os mesmos a razão pela qual não se obteve nenhuma pessoa, como testemunha, estranha aos quadros da polícia. Essa verificação é essência, pois uma apreensão de drogas feita à vista de inúmeras pessoas, em local público, por exemplo, pode perfeitamente contar com o testemunho de pessoas que não sejam policiais. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2009, p. 353).

Assim, cumpre indagar, ante aquilo que foi exposto, se o quanto relatado pelo policial pode, na hipótese em tela, ser considerada uma prova robusta e coerente para fins de fundamentalmente arrimar uma condenação por tráfico de drogas. No entendimento deste Juízo, não é.

Forçoso, in casu, verificar que, tendo negado o réu a propriedade ou porte da droga em juízo, e não havendo, além da declaração dos policiais, qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Mercancia não comprovada - Indícios insuficientes para formar convicção nesse sentido - Réu preso em companhia de menor reconhecido e indicado como traficante - Ausência de atos seguros e concretos vinculando suas ações - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido - (TJSP, APELAÇÃO Nº: 990.09.047397-5 - COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA APTÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS APDO : Ministério Público).

Assim, a despeito da probabilidade da ocorrência do tráfico de drogas, o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação por tráfico de drogas pelo acusado.

Destarte, nesta fase processual, encerrada a instrução, se alguma dúvida existe deverá ser interpretada em favor do réu, conforme recomenda a boa técnica processual penal.

Como é cediço, em casos de dubiedade, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição da acusada como medida de justiça. Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2008, p.178/19):

"...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos."

"Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo"

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câmb., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313

No mais, conforme leciona o Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 150 ), membro do Ministério Público de São Paulo:

“A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva.

Quando se tem presente, salientou Malatesta, que a condenação não pode basear-se senão na certeza da culpabilidade, logo se vê que a credibilidade razoável – também mínima – da inocência, sendo destrutiva da certeza da culpabilidade, deve, necessariamente, conduzir à absolvição”.

Com efeito, uma sentença judicial condenatória deve ser embasada em elementos objetivos, contundentes e sólidos. Em verdade, para fins de condenação criminal, a intuição deste julgador não tem qualquer importância. Não basta a crença, deve haver certeza.

Novamente, colaciona-se o escólio do Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 15):

A respeito, obtempera Heleno Cláudio Frágoso que “a condenação exige certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de nossa mente em torno da existência de certa realidade”. Mesmo a íntima convicção do Juiz – pondera Sabatini –, como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação (g.n.), não é verdadeira e própria certeza (...); no lugar da certeza, em espécie tal, tem-se a simples crença.

O entendimento do nobre membro ministerial é de rara sabedoria e desmerece contestações.

Como se vê, no caso em tela, mesmo diante da suposta localização da droga, e considerando, as inconsistências apontadas, e o conjunto probatório produzido, e que a prova produzida pelo órgão acusador se restringe, basicamente, ao testemunho policial – que são a reprodução das declarações que constam em inquérito – os elementos amealhados no curso da instrução penal não permitem concluir com segurança necessária que o acusado praticava o crime inserto no art. 33 da lei 11.343/06. Com isso, destaque-se, não se conclui pela necessária ocorrência de um flagrante forjado, mas sim, pressupõe-se que, havendo dúvida do que ocorreu na data dos fatos, deve ser aplicada a máxima mencionada, já que a dúvida milita em favor do acusado.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e ABSOLVO o réu MARCUS VINICIUS DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, de todas as imputações que lhe foram dirigidas, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Cautelas e comunicações de estilo.

Havendo demais bens ou valores apreendidos, excetuado o veículo acima, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreto a perda da integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

P.I.C.

Aruja, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA